

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)



INSTITUT DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (IRMAP)



ACTIVITE SCIENTIFIQUE DU MASTER

INTRODUCTION AU DROIT FRANÇAIS DES MARCHÉS PUBLICS

PRÉSENTÉ PAR CHARLES ERIC THOOR

Avocat, collaborateur sénior - Cabinet Bignon Lebray France

CELLULE DE COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLICS CCRP-ARMP

Copyright, Décembre 2022

INTRODUCTION AU DROIT FRANÇAIS DES MARCHÉS PUBLICS

Sur invitation du Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), Me Charles-Éric THOOR a délivré un cours sur le droit français de la commande publique aux étudiants du Marchés de la commande publique de l'IRMAP.

Cette formation vise à fournir à l'administration de ressources humaines qualité capable de conduire les procédures de passation des marchés publics.

L'occasion a été également saisie pour recevoir les assistants en passation des marchés publics qui ont démarré leur stage grâce à l'accompagnement de la Direction de l'emploi qui appuie les autorités contractantes et les opérateurs privés qui les accueillent.

Pour rappel, ce Master qui en est à sa septième (7eme) promotion, est le fruit d'un partenariat entre l'Ecole Nationale d'Administration, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

Nos remerciements au professeur Abdoulaye SAKHO, coordinateur du Master qui a facilité le déplacement du brillant avocat.



MINI DOSSIER- MARCHÉS PUBLICS

La préférence nationale et ses limites



Lors d'une conférence organisée, samedi, par le Master en régulation de l'ARMP, des experts et de hauts cadres de l'institution sont revenus sur les enjeux de la dématérialisation des procédures, les ambitions affichées pour la préférence nationale et leurs limites, la prudence nécessaire dans les PPP...

Réserver aux PME sénégalaises et communautaires 15 % dans les marchés de la commande publique. Voilà un vœu des pouvoirs publics longtemps exprimé, mais dont la mise en œuvre pose toujours problème. En fait, malgré les déclarations d'intention, les privés nationaux et communautaires peinent à profiter pleinement des marchés publics dans les mêmes proportions que leurs concurrents étrangers. La thématique a aussi été abordée, ce samedi, lors d'une importante conférence organisée par le Master en management de la régulation des marchés publics de l'ARMP.

Ancien président du Conseil de régulation de cette institution et formateur à l'IRMAP, Monsieur Mansour DIOP explique : "La perspective qui est poursuivie par les autorités au plus haut niveau est un objectif louable qui consiste à faire participer le tissu économique sénégalais à la commande publique. Ça, c'est l'objectif politique. Comment matérialiser cela ? C'est tout le problème. La déclaration a été faite ; il y a même certaines autorités contractantes qui tentent de l'appliquer, mais cela n'a pas encore de base juridique".

Confirmant ce vide qui existe, le Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques (DRAJ) de l'ARMP, le Dr Baye Samba DIOP a relativisé et rappelé tout un ensemble de dispositifs prévus dans divers textes, depuis la loi de 2008 sur les PME remplacée par celle de 2020. Laquelle a prévu une obligation pour le ministère chargé des PME de dresser un rapport sur la part des marchés publics attribuée aux PME. Dans la même veine, il y a tout un ensemble de dispositions accordant des marges préférentielles aux startups, ainsi qu'à certaines entreprises de l'économie solidaire rappelées par M. Diop. "Pour les PME, insiste-t-il, il y a l'allotissement qui a été prévu, mais ce n'est pas une obligation..."

Il n'y a pas de base juridique pour réserver 15 % des marchés aux PME

Saluant ces politiques préférentielles mises en place par l'État en faveur des privés nationaux, Mansour Diop a relevé la nécessité d'une mise à niveau de ces PME. Il y a deux préalables, selon lui, pour que ces acteurs puissent pleinement en profiter. D'abord, ces privés nationaux doivent davantage se formaliser et se mettre à niveau. Ce qui est loin d'être le cas, d'après lui. Ensuite, il faut qu'elles s'imprègnent des règles de la commande publique. "On ne peut pas prétendre à la Commande publique, si on n'a pas les rudiments qui régissent cette Commande publique. Si les deux sont réunies, pourquoi ne pas aller au-delà des 15 % ? Je pense qu'on pourrait aller bien au-delà, si toutes les conditions sont réunies".

Cette question de la préférence nationale, selon le professeur Abdoulaye SAKHO, Directeur du Master en régulation de l'ARMP, est un gros problème, en raison des engagements internationaux des États. "Normalement, il y a beaucoup d'activités qui sont libéralisées.

La question de nationalité ne se pose plus sur beaucoup de plans. C'est une libéralisation peut-être à l'extrême Mais dans les faits, les pays, de plus en plus, conservent les frontières. Chacun essayant de préserver ses intérêts comme il peut. Il s'agit d'intégrer un certain nombre de dispositifs internationaux dans le champ national".

L'art de contourner les engagements internationaux.

Par exemple, note-t-il à titre indicatif, si on prend les subventions faites à des secteurs dans certains pays, il y a des normes internationales qui l'interdisent. "Mais on sait qu'il y a de grands pays qui subventionnent leur agriculture ou d'autres secteurs. C'est une question à qui mieux mieux ; qui est le plus intelligent dans la manière de contourner cette réglementation. C'est ça l'enjeu, il faut juste être intelligent".

De l'avis de Maître Charles ERIC - THOOR, Avocat au cabinet Bignon Lebray, invité du Master en régulation pour cette master class, en France, il faut noter que c'est partout pareil cette ambition de donner les grands marchés à des nationaux.

"Aucune autorité n'aime financer autant d'argent et les voir filer par exemple en Roumanie, en Bulgarie ou en Pologne. Ça les énerve quand ça arrive.

On essaie parfois avec des moyens indirects comme la longueur pour diminuer l'empreinte carbone...C'est une manière détournée de favoriser les entreprises françaises à l'aide de critères objectifs et même parfois louables. On a même eu à parler de clause Molière pour imposer à chacun de savoir parler français. Évidemment, cela n'est pas allé plus loin...", a souligné l'expert, non sans préciser qu'en France, on ne saurait parler de préférence nationale en raison des engagements internationaux.

Des engagements qui sont à peu près les mêmes que ceux du Sénégal, a tenu à préciser le Professeur Abdoulaya SAKHO.

PASSATION DES MARCHÉS : Vers une dématérialisation des procédures

Si la volonté de l'Autorité de régulation des marchés publics et de certains acteurs se matérialise, d'importants changements vont intervenir dans la gestion des procédures de passation des marchés publics.

La question de la dématérialisation des procédures a également été abordée par les intervenants. Dans un pays comme la France, a soutenu Me ThOOR, les procédures sont entièrement dématérialisées. Ce qui renforce non seulement la transparence dans les procédures, mais aussi l'efficacité.



Selon l'ancien président du Conseil de régulation de l'ARMP, il faut bien qu'on en arrive à ce stade, au Sénégal. Interpellé sur cette question, il déclare : "Du point de vue de la célérité, on peut avoir quelques reproches. Mais on a été rassuré par le projet qui nous a été présenté et qui, à terme, va nous valoir un dispositif extrêmement pertinent, extrêmement adapté. Nous sommes dans un domaine où il ne faut pas se précipiter. Il y va de la transparence, de l'efficacité, de la sécurité des procédures. Il faut certes dématérialiser, mais il ne faut pas se précipiter. Un travail important est en train d'être fait pour avoir le dispositif le plus important."



Dans son intervention, le Directeur des Statistiques et de la Documentation (DSD) de l'ARMP, Monsieur Ousseynou CISSE, est largement revenu sur les efforts qui sont en train d'être déployés à ce niveau.

"Depuis le départ, l'ARMP avait mis en place le système intégré de gestion des marchés publics avec la DCMP. Mais c'est un système qui avait un champ un peu restreint ; il permet juste de dématérialiser la partie planification et la partie Suivi des marchés.

Conscients des limites du SYGMAP, les services vont très tôt mettre en place un autre système qui permet de gérer la partie soumission électronique. Il a certes eu des retards, parce qu'il fallait s'assurer de toutes les garanties de sécurité et de transparence, mais actuellement, la phase technique a été achevée. L'année 2023 devrait être une année de lancement. Nous allons démarrer avec quatre autorités contractantes que nous allons élargir au fur et à mesure".

Il faut noter que cette question est une priorité de l'UEMOA. Lors de la 25e réunion de l'Observatoire régional des marchés publics (ORMP) de l'organisation, la commission avait invité les États membres à faire une présentation sur l'état de mise en œuvre de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. À cette occasion, l'ARMP avait fait une présentation de son système dénommé KERMELE.

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ : Attention aux dérives !

Lors de cette conférence, les participants sont également revenus sur les partenariats public-privé qui semblent avoir un peu le vent en poupe en Afrique en général et au Sénégal en particulier.

Très sexy pour les autorités contractantes qui ne cessent d'en faire la promotion, les partenariats public-privé comportent cependant des risques qu'il faudrait bien adresser. L'exemple de la France, où il y a eu plusieurs abus en matière de PPP, a d'ailleurs été rappelé au cours de la conférence par Me Charles-Eric THOOR.

Il s'empresse d'ailleurs de préciser : "Il ne faut pas se tromper. Le PPP, c'est une très bonne formule, une manière de commander des ouvrages techniques de haut niveau et d'avoir une exploitation qui vient derrière par un professionnel. Ce n'est pas une formule à condamner. Bien au contraire, il faut l'encourager et le poursuivre." Toutefois, indique le spécialiste, il faut juste être conscient qu'un PPP, c'est un contrat qui est engageant pour les pouvoirs publics. "On ne l'utilise pas pour aller acheter des légumes ou des cantines, mais pour acheter des infrastructures. Qui dit projet de cette ampleur, dit aussi qu'il faut faire attention. Il ne faut pas se jeter à corps perdu dans les PPP. Il faut être conscient du coût que cela implique. J'ai quand même le sentiment qu'ici (au Sénégal) on en est conscient. Le conseil que je peux donner, c'est d'essayer d'impliquer le maximum de professionnels qui pourront s'assurer que les contrats qui sont soumis à la signature répondent bien à l'intérêt général poursuivi".

Embouchant la même trompette, le professeur Abdoulaye SAKHO trouve que les PPP sont une excellente chose.

"En fait, il peut y avoir un problème par rapport à l'utilisation qui est faite de la réglementation sur les PPP. Mais en ce qui concerne la réglementation en tant que telle, c'est nickel. On n'a pas grand-chose à dire. Maintenant, comme dans toute chose, l'utilisation peut poser problème", soutient le directeur du Master, non sans souligner que l'essentiel pour l'État, dans le domaine des marchés publics, quelle que soit la forme, c'est d'obtenir le service ou le bien à moindre coût pour les finances publiques et que ça soit de qualité.

La problématique des offres spontanées

Par ailleurs, dans le fond, indique-t-il, une question peut se poser sur la soumission des PPP à la loi sur la commande publique.

"Il faut se demander si c'est la loi sur la commande publique qui est applicable ou la loi sur l'investissement", s'interroge-t-il avant d'ajouter à propos spécifiquement des offres spontanées : "

Pour moi, il faut qu'on fasse attention, parce que c'est un privé qui vient mettre son argent dans un premier temps pour les besoins d'un État. Par exemple : moi je suis un privé ; j'ai identifié un projet ; j'amène mon argent ; je le mets là-dans et on me dit : non, il faut faire un appel à concurrence. Est-ce du droit de la Commande publique ou est-ce du droit de l'investissement ? Je pense qu'il y a là matière à réfléchir."

Pour le moment, l'État semble avoir opté pour l'application de la réglementation sur la commande publique. Et des conséquences importantes en découlent.

Elles sont rappelées par le Pr. SAKHO, il renseigne : "Il faut savoir que quand c'est le droit de l'investissement, on ouvre tout. L'entreprise ne paie même pas les impôts. On lui déroule le tapis. En revanche, quand c'est la Commande publique, on vous dit : il faut faire concurrence avec tel. Or, ceux qui font ces offres, ce sont des fonds d'investissement. Ils viennent vous proposer la construction d'un stade, vous leur dites oui, mais il faut me donner le projet pour que je lance un appel à concurrence. Qu'est-ce qui lui dit que tu ne vas pas présenter l'offre à un autre ? Voilà les questions qui se posent à ce niveau."



PR ABDOULAYE SAKHO, AGREGÉ DE DROIT ECONOMIQUE

« Il faudra utiliser le code des marchés publics pour des objectifs sociaux »

Le code des marchés publics tel qu'il est libellé actuellement n'est pas mauvais, selon Pr Abdoulaye SAKHO. Mais le juriste qui s'exprimait en marge d'une conférence pour le master management de régulation des marchés publics de l'ARMP, note néanmoins qu'il faudra utiliser ce Code pour des objectifs beaucoup plus sociaux.



Il est une voix autorisée de la régulation des marchés, au Sénégal et en Afrique.

En effet, professeur agrégé de droit privé, Pr Abdoulaye SAKHO est un des artisans du code des marchés publics du Sénégal. Toutefois, même s'il trouve que ce code n'est pas mauvais, Pr SAKHO pense qu'il peut être amélioré pour prendre en charge d'autres problématiques actuelles.

En effet comme en France où la loi Climat et résilience, n°2021-1104 du 22 août 2021 publiée au Journal officiel inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l'exécution des contrats de la commande publique en modifiant et complétant le code de la commande publique, l'enseignant soutient : « Il faudra utiliser les dispositions du code des marchés publics pour peut-être des objectifs économiques. Comment faire pour que les petites et moyennes entreprises puissent bénéficier des objectifs sociaux ? Comment faire pour que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier de tout cela parce que ce sont des Sénégalais comme tout le monde ? On peut utiliser cela pour les inclure ». À l'en croire aussi, comment faire pour qu'il y ait des préoccupations, surtout celles liées au climat, à l'environnement ? Il souligne que le code aujourd'hui a réglé ces questions. Mais avoue-t-il, peut-être pas de manière satisfaisante pour tout le monde.

S'exprimant en outre aussi sur l'épineuse question de la préférence nationale, le Professeur SAKHO a fait savoir que c'est un gros problème.

« La préférence nationale est un gros problème. Car on a des engagements internationaux comme l'UEMOA, la CEDEAO mais aussi l'OMC. Il y a beaucoup de domaines d'activités qui sont libéralisés et dans lesquels, peu importe votre pays d'origine, vous pouvez aller fonctionner dans un autre pays », renchérit-il non sans signaler que la condition de nationalité ne se pose plus sur beaucoup de domaines.

C'est un problème d'introduction des dispositions internationales, d'après lui, dans le champ juridique national.

Ancien président du Conseil de régulation de l'ARMP et actuellement formateur à l'IRMAP, Monsieur Mansour Diop a affirmé pour sa part que les marchés publics sont par essence évolutifs. « Et on a besoin de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour renforcer le dispositif qu'on a qui est à mon avis pertinent, qui est efficace mais qui a besoin parfois sur certains aspects d'être amélioré », note l'administrateur civil.

Revenant en outre sur la dématérialisation de l'ARMP, il déclare : « Il y a une marge de progression que l'ARMP n'a pas forcément saisie. Du point de vue de la célérité, on peut avoir quelques reproches ».

Indiquant toutefois que dans ce domaine, il ne faut pas se précipiter. Car, renseigne ce haut cadre de la régulation, il y va de la transparence et de l'efficacité. « Oui, il faut dématérialiser mais pas dans la précipitation. Il faut avoir tous les atouts de son côté pour pouvoir le faire », prévient-il.



COMMANDE PUBLIQUE

L'ARMP capitalise l'expertise française

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) tient à se performer. Et pour ce faire, elle a organisé samedi dernier une conférence dont l'objectif était de s'inspirer de ce qui se fait de meilleure en matière de passation des marchés publics en France. La conférence s'est tenue à l'Institut de régulation des marchés publics (IRMAP).



De l'avis de Monsieur Mansour DIOP, premier président du Conseil de régulation de l'ARMP, : « On a besoin de s'améliorer parce que les marchés publics, c'est un domaine par essence évolutif ». Donc, « s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour s'améliorer, pour renforcer le dispositif qu'on a, qui est un dispositif qui est à mon avis pertinent, qui est efficace, mais qui a besoin parfois sur certains aspects d'être développé », a-t-il expliqué.

Pour ce qui est de la dématérialisation, M. DIOP se dit rassuré par le projet décrit par le Directeur des Statistiques et de la documentation en l'occurrence Monsieur Ousseynou CISSE. A l'en croire, « ce projet à terme va nous valoir un dispositif extrêmement pertinent et adapté. Parce que dans ce domaine si tu y vas un peu de la transparence, il y va également de l'efficacité des procédures ».

Le professeur Abdoulaye SAKHO, Directeur du Master, donnant son avis sur la flexibilité ou non du code des marchés publics sénégalais a dit que : « Le code des marchés est flexible mais par moment il est assez rigide aussi. Tout dépend de la phase dans laquelle on est. Mais, c'est un bon code actuellement d'autant plus que sur la base de ce code, l'ARMP a fait d'énormes progrès dans le contrôle ».

Ce qui lui fait dire que « le code n'est pas mauvais ». Mais, « c'est peut-être la manière dont on l'applique qui ne ménage pas les choses », a relevé l'expert en commande publique. Sous ce rapport M. SAKHO n'exclut pas des changements à ce niveau, car selon lui, « plus on avancera, peut-être on aura besoin de modifier certaines choses. On a parlé de la dématérialisation, elle est là. Il faut la faire de manière très intelligente.

Il faudra utiliser les dispositions sur le code des marchés publics pour peut-être des objectifs économiques », a-t-il recommandé.

Le Quotidien MARCHES Dématérialisation des procédures de passation La phase-pilote démarre en 2023



L'Agence de régulation des marchés publics va complètement dématérialiser les procédures de passation des marchés publics. C'est ce qu'a annoncé Ousseynou Cissé. Le directeur des Statistiques et de la documentation de l'ARMP a indiqué que 4 institutions sont ciblées pour démarrer la phase-pilote en 2023.

Comment rendre plus efficiente la Commande publique ? C'est une question que se posent toutes les démocraties du monde. Si certains pays ont choisi de mettre la transparence comme boussole, quitte à allonger la lourdeur administrative, d'autres ont opté pour le progrès. En utilisant internet pour l'avis de commande et la soumission, c'est un gain de temps considérable qui est fait en plus d'assurer la transparence.

Le Sénégal a fait ce choix. Si depuis 2008, on parle de dématérialisation du processus, Ousseynou Cissé a assuré que l'ARMP va l'appliquer. Il donne rendez-vous en 2023 pour le lancement de la phase-pilote qui devrait commencer qu'avec

4 institutions. « Je peux vous assurer que la dématérialisation est un souhait. Il fallait faire des études pour savoir les avantages, les inconvénients et la faisabilité. Nous allons lancer la phase-pilote en 2023. Nous avons choisi d'enrôler 20 institutions, mais on a été obligé de commencer le test qu'avec 4 », a déclaré le directeur des Statistiques et de la documentation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics

(ARMP) samedi, lors de la conférence organisée pour le compte du master en management Régulation des marchés publics. « Le projet est achevé. Nous avons acheté des certificats », a-t-il précisé, en présence de Charles-Eric THOOR, du cabinet Bignon Lebray de la France.

L'avocat était invité à faire une étude comparative des cadres légaux de la Commande publique du Sénégal et celle de la France. « Du point de vue de la célérité, on peut avoir quelques reproches, mais on a été rassuré par le projet qui nous a été présenté et qui à terme, va nous valoir un dispositif extrêmement pertinent, extrêmement adapté. Nous sommes dans un domaine où il ne faut pas se précipiter. Il y va de la transparence, de l'efficacité, de la sécurité des procédures. Il faut certes dématérialiser, mais il ne faut pas se précipiter. Le travail qui est en train D'être fait pour avoir le dispositif le plus important me semble important », a ajouté Mansour DIOP l'ancien du conseil de régulation de l'ARMP.

Une position partagée par le professeur Abdoulaye Sakho. Qui voit dans la dématérialisation une façon d'inclure tout le monde. « Utiliser les dispositions du Code des marchés publics pour faire en sorte que les Pme puissent bénéficier des marchés. Faire en sorte que les personnes en situation de handicap par exemple, puissent en bénéficier. Prendre en charge les préoccupations d'ordre environnemental. Il s'agit de prendre en charge tout cela. Nous le faisons. Peut-être pas de manière satisfaisante, mais on le fait. On pourra les améliorer », a-t-il détaillé.

D'après Me ThOOR, le Sénégal est la locomotive d'un train qui va vite, l'Afrique de l'Ouest. En plus d'être dans une logique de rattrapage, la communauté ouest africaine ne peut faire abstraction des éléments exogènes qui viennent bouleverser les certitudes, a détaillé l'avocat d'affaires.

Ainsi, selon Me THOOR, « l'essentiel du droit de la Commande publique a été pris en compte dans le Code des marchés publics. L'architecture du contrôle est totalement différente entre les deux pays. En France, le Code de la Commande publique regroupe trois catégories. Qui sont les contrats de marchés publics avec comme sous-catégorie, le marché des partenariats, les conventions d'occupation du domaine public et le statut d'acheteurs publics qui sont soumis à beaucoup d'obligations ».



le soleil AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE**La dématérialisation des procédures, le chantier majeur pour 2023**

Avec déjà un bon code, l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) compte mettre l'accent, en 2023, sur la dématérialisation des procédures qui s'imposent comme l'un des chantiers majeurs.



L'Institut de formation de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a organisé samedi dernier, un atelier d'échanges à l'intention de ses étudiants du Master.

La séance animée par l'avocat Charles-Éric THOOR, du Cabinet Bignon Lebray France, a vu la présence de spécialistes du droit et experts de la régulation des marchés publics. De l'analyse du Code des marchés publics français faite par Charles-Éric THOOR ressort un modèle assez développé de la dématérialisation des procédures.

Au Sénégal, l'Autorité de régulation de la commande publique compte corriger les manquements selon Mansour DIOP. « On a besoin de s'améliorer parce que les marchés publics sont un domaine par essence évolutif. Nous avons un dispositif pertinent et efficace mais qui a besoin sur certains aspects d'être amélioré. Il y a une marge de progression que l'ARCOP n'a pas forcément saisie. Du point de vue de la célérité, on peut faire quelques reproches.

Le projet de dématérialisation va à terme nous valoir un dispositif pertinent et adapté », a déclaré M. DIOP. Et l'adaptation se fera dans le court terme, assure Ousseynou CISSE, directeur de la statistique et de la documentation. Pour cet expert de l'ARCOP, la dématérialisation est le chantier de 2023.

Ainsi, souligne-t-il, l'ARMP est dans cette dynamique, notamment avec la mise en place du Système électronique de gestion des marchés publics (SYGMAP). « Nous sommes conscients de l'importance de la dématérialisation pour plus d'efficacité et de transparence. Nous travaillons sur le projet qui constitue le chantier pour 2023 », a affirmé Ousseynou Cissé.

Cette avancée contribuerait à parachever un code des marchés publics performant, selon le professeur Abdoulaye SAKHO. « Plus on avancera, plus on aura besoin d'améliorer certaines choses. Ce code est assez flexible mais rigide par moments. C'est un bon code actuellement. Vous voyez les chiffres de l'ARCOP. Même dans le contrôle, d'énormes progrès ont été enregistrés. Maintenant, il faudra faire la dématérialisation de manière intelligente en utilisant les dispositions sur le code des marchés publics afin que les Petites et moyennes entreprises puissent bénéficier des avantages sociaux. On peut l'utiliser pour inclure tous les citoyens comme cela se fait ailleurs », a expliqué le professeur Abdoulaye SAKHO.

CELLULE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES (CCRP)



Rue Alpha Hachamiyou TALL x Kléber



(+221) 33 889 11 60 / (+221) 33 821 08 13



armp@armp.sn

<http://www.armp.sn/>